

1501214-81.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

...

Por mais que fosse trabalhoso dirigir-se por diversas ao ponto de tráfico, certamente assim proceder seria muito menos arriscado do que transitar com grande quantidade de droga e ser confundido com um traficante.

Para o senso comum, é preferível perder tempo para ir várias vezes ao ponto de tráfico do que se arriscar a ser preso como um traficante que transporta quase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501214-81.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501214-81.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297897/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21152206 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 7959/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2297897 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 7959/21/050 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ROBSON APARECIDO DE LIMA FRANCISCO e JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS foram dados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 01 de novembro de 2021, por volta das 22h10, na Avenida Castelo Branco, esquina com a rua Marcel Pinto de Oliveira, Jardim Ouro Verde, nesta cidade, transportavam, para fins de tráfico, 708,10 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificados (fls. 145 e 147), os réus apresentaram as defesas preliminares de fls. 130/134 e 157/158.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 18 de janeiro de 2.022 (fls. 167/169).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 202 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 211/214).

Já a defesa técnica do réu Júlio César se manifestou a fls. 221/256, alegando que:

1)- a droga não estava fracionada e não havia instrumento que permitisse o fracionamento, a embalagem, a pesagem e a revenda em porções próprias para venda; 3)- a narrativa dos policiais de que os réus dispensaram cerca de mil pinos é absurda, pois eles nada viram, mencionaram que perderam o veículo de vista e, ao refazerem o trajeto, nada encontraram; 4)- não é comum que duas pessoas, sem os petrechos necessários, saiam comercializando drogas num veículo, sem ponto determinado e fixo; 5)- os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação; 6)- a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois o réu declarou que iria consumir a maconha em cerca de um mês, que compra tal quantidade para não precisar voltar para Bauru ou ir em biqueira diariamente ou semanalmente, que recebia mensalmente R\$ 2.500,00 e que morava com os pais; 5)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O acusado Robson apresentou as alegações finais de fls. 258/261, aduzindo que: 1)- Júlio César negou dar qualquer depoimento e disse que somente falaria em juízo; que mora em Piratininga, mas naquela noite estava em Bauru para encontrar sua irmã; antes de ir até onde ela estava, passou pela Vila Santista, adquiriu droga e depois encontrou Robson, que lhe pediu carona para ir à residência de sua mulher; os policiais não deram sinal de parada e seguiu dirigindo normalmente; percebeu que a polícia estava muito perto de seu carro ficou nervoso e colidiu o carro; 3)- Robson afirmou ter pedido carona a Júlio César a fim de visitar seu filho que morava no residencial Monte Verde; não sabia que havia droga no carro; quando pegou a carona, estava perto do residencial; não sabe dizer quantas quadras o veículo percorreu desde que nele adentrou até a abordagem; Júlio César, quando passou a acelerar o automóvel em razão da presença da viatura, disse-lhe que a documentação estava atrasada; 3)- com Robson, não foram encontrados produtos ou apetrechos que o ligassem ao tráfico; 4)- a delação anônima não o apontou; 5)- não há prova do liame subjetivo. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelos autos de apreensão de fls. 18/19 (um telefone celular: R\$ 423,00; R\$ 60,00; e entorpecente) e 20 (veículo Ford Focus) e pelo laudo pericial de fls. 205/208 (uma porção de maconha com peso de 691,32 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos aos acusados.

Em juízo, a testemunha Jurandyr Ferreira da Silva Júnior, policial militar, afirmou que, quando realizava patrulhamento pelo bairro Ouro Verde, recebeu a informação de que indivíduos, a bordo de um veículo Ford Focus, estariam praticando o tráfico na região. Em uma das ruas do bairro, o veículo foi encontrado. Deu ordem de parada, mas o condutor não obedeceu. Iniciou então um acompanhamento do automóvel por várias ruas. No cruzamento da rua Marcel Pinto de Araujo com a Avenida Castelo Branco, o veículo perseguido se envolveu em um acidente, colidindo com outro automóvel. De imediato, foi feita a abordagem. Nas buscas pessoais, foram encontradas quantias em dinheiro com ambos os acusados. Em revista no veículo, foi localizado um tablete de maconha. Indagados, os réus negaram a posse do

entorpecente e disseram não saber da presença desse material. No entanto, eles falaram que havia mil pinos vazios que seriam usados para acondicionar cocaína. Os pinos não foram, contudo, encontrados, nem no veículo tampouco nas ruas percorridas durante a perseguição. O entorpecente apreendido estava sob o banco do motorista. Não se recorda se os réus informaram quem seria o proprietário do automóvel. Eles também não mencionaram ter fugido da abordagem em razão de o veículo estar com documentação irregular. A denúncia anônima somente dizia que indivíduos traficantes estavam a bordo de um Ford Focus naquela região.

A testemunha Jairo Araújo Lima, também policial militar, disse ter recebido informação de que os ocupantes de um veículo Ford Focus, de cor cinza, estariam praticando tráfico. Com base em tais informações, foi iniciada patrulha em busca do veículo citado. Em dado momento, deparou-se com o carro em questão, o qual tentou fugir e veio a colidir com outro automóvel. Foram então efetuadas a abordagem e a busca no veículo. Sob o banco do motorista, foi localizado um tijolo de maconha. Indagados, os réus negaram a propriedade do entorpecente. Foram dados sinais de parada sonoros e luminosos aos réus, mas eles não obedeceram. O réu Júlio César era o condutor do veículo. Ele portava quatrocentos e vinte de três reais. Com o réu Robson, havia cerca de sessenta reais. Nenhum dos dois disse ser o dono da droga. Eles afirmaram que havia mil pinos para acondicionamento de cocaína, ainda vazios, os quais teriam sido dispensados pelo caminho. Porém, tais objetos não foram localizados. O veículo não estava registrado em nome de nenhum dos acusados. Eles não informaram por qual motivo estavam na posse do automóvel. Os réus viram o encontro da droga pelos policiais, já que acompanharam a busca. Os dois negavam, ainda assim, a propriedade do entorpecente. Não se recorda se havia alguma irregularidade administrativo no veículo.

Interrogado em juízo, o réu Júlio César disse que ele e Robson se negaram a prestar depoimento aos policiais e lhes disseram que somente iria dar declarações ao juiz. Estava em Piratininga e sua mãe pediu para que fosse até a casa de sua irmã passar um recado a ela. Veio para Bauru. A droga era sua. Não chegou a ir na casa de sua irmã para dar o recado. Passou pela Vila Santista e pegou a droga. Perto do Jardim Vitória, encontrou Robson e este lhe pediu carona até a esquina debaixo. Aceitou oferecer a carona e Robson entrou no carro. Próximo da casa da esposa de Robson, foram abordados pelos policiais. Tem o costume de dirigir em alta velocidade. Os policiais não deram sinal de parada. Viu pelo retrovisor que a viatura estava vindo atrás e encostando muito perto. Como estava com a droga no carro e com documento atrasado, ficou com a cabeça quente e colidiu com uma caminhonete. Os policiais os revistaram e disseram ter achado a droga. Ele e Robson nada disseram e explicaram que somente fariam na audiência de custódia. A droga não seria destinada ao tráfico. Não é traficante. Descendo para o Jardim Vitória, em sentido à casa de sua irmã, encontrou-se com Robson. Iria deixá-lo no local para o qual ele iria. Havia acabado de pegar o entorpecente. Costuma comprar por mês, para não ter que ir em boca de fumo. Pagou oitocentos reais pelo entorpecente. Obteve o dinheiro trabalhando. Trabalhava com seu pai, como ajudante de pintor, quando foi preso. Tem seus pais e seus irmãos. Robson estava na rua. Como ele o conhecia, deu-lhe com a mão e pediu carona. Robson não sabia que havia droga no carro. Ele falou que a carona seria apenas até a próxima esquina, na casa de sua mulher. Isso é modo de dizer. Robson disse que a carona era até mais adiante. A esposa dele morava no bairro Ouro Verde. Não sabe o endereço exato dela. Pegou Robson no início da rua Giocondo Turini, perto de uma creche, a cerca de quatro quadras de onde ocorreu a abordagem. Nunca houvera sido abordado pela polícia. Iria deixar Robson, passar em sua irmã, dar-lhe o recado e seguir embora para Piratininga. Veio da Vila Santista, para onde foi primeiro. Avistou Robson e lhe deu carona. Depois de deixá-lo, iria na casa de sua irmã e, em seguida, iria embora. Trabalha desde os 16 anos. Estava trabalhando com reflorestamento ambiental. Considera-se tratorista e tem dois certificados. Seu pai lhe pagava cem reais por dia. Chegava a auferir cerca de dois mil e quatrocentos ou dois mil e quinhentos reais. Residia com seu pai. Ele é vigilante do Poupatempo. Não tem necessidade econômica de vender drogas. Sempre trabalhou e se esforçou. Comprava entorpecente para durar o mês todo, a fim de não acontecer o que aconteceu.

Interrogado em juízo, o réu Robson negou a propriedade da droga. Não sabia que ela estava no carro. Pegou carona com Júlio para ir até a casa de sua esposa, a fim de ver seus filhos. Eles residem no Residencial Monte Verde. Pegou a carona uma quadra para frente da rua Giocondo Turini. O residencial se situa perto do local onde pegou a carona. Não sabe explicar a distância. Não sabe quantas quadras o carro percorreu até a abordagem. Júlio não explicou por qual motivo fugiu da abordagem policial. Ele disse apenas que estava com documentos atrasados.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em suas defesas.

Afasta-se, inicialmente, a alegação de que a diligência realizada pelos policiais teria redundado em prova nula, sob argumento de ter partido de denúncia anônima. É certo que tal fonte, isoladamente, não se presta a embasar decreto condenatório. No entanto, serve, sim, a servir de ponto inicial para investigações e diligências por parte da polícia, como ocorreu no caso.

Vale a observação de que boa parte dos crimes somente são descobertos e investigados a partir de notícias anônimas recebidas pela polícia.

Se não fosse tal fonte inicial, a polícia estaria tolhida de investigar e prevenir a prática de infrações penais, com sensível prejuízo à sociedade.

Destarte, afirmar, simplesmente, que a delação anônima não pode servir de ponto de partida para atuação da polícia é advogar tese contrária ao interesse público.

Frise-se que, com a posição adotada, não se está a ferir o contraditório e a ampla defesa, pois não se está admitindo a notícia anônima como exclusivo elemento de prova em detrimento dos réus, mas apenas levando-a em consideração para dar supedâneo ao início das investigações.

Observe-se, no particular, que a presente decisão não faz, em momento algum, alusão ao teor da informação anônima como elemento de convicção para embasar o decreto condenatório, mas apenas considera os demais dados a partir dela obtidos.

Portanto, a prova produzida não é nula, apenas porque partiu de notícia anônima da prática de crime.

Prosseguindo, é certo que os réus, quando interrogados em juízo, negaram a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que flagraram os réus transportando mais de 700 gramas de maconha, encontrados sob o banco do motorista do veículo no qual eles estavam.

Não colhe o argumento de que os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação.

No particular, é lícito questionar: por que razão dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em juízo para, na presença do magistrado, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoas que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação? Ademais, as afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

A alegação de Robson, no sentido de que apenas pegou uma carona e não sabia da presença da droga no veículo, não convence.

Ele relatou que iria até a casa da esposa para visitar os filhos, moradores do Residencial Monte Verde.

No entanto, nada comprovou nesse sentido, nada obstante a demonstração do alegado fosse muito fácil de produzir.

Com efeito, poderia ele ter arrolado a esposa como testemunha, a fim de que ela comparecesse em juízo para dizer que, naquela data, o réu estava sendo esperado na residência dela para ver os filhos.

A inércia da defesa, no ponto em questão, é sintomática.

Outrossim, causa espécie que Robson não tenha sabido dizer quantas quadras o veículo percorreu, desde o momento em que nele adentrou, até à abordagem policial.

Se, segundo os próprios acusados deram a entender, o início da carona ocorreu em local já próximo do destino indicado como sendo o de Robson (Residencial Monte Verde), não é possível que ele não tivesse uma noção aproximada da distância percorrida enquanto esteve no veículo de Júlio César.

Mormente se se considerar que ele estava seguindo a pé quando pegou a carona e certamente era sabedor do local de residência da esposa e filhos.

Não se concebe, pois, que não soubesse a distância percorrida.

Sua fala, no sentido de que a ignorava, somente permite concluir que ele faltou com a verdade e que a mentira teve sua razão de ser no fato de que Robson não pegou carona nas proximidades e nem se dirigia à casa da esposa para ver os filhos.

Enfim, pois, está demonstrado que ambos os réus transportavam o tijolo de maconha encontrado no carro.

Noutro aspecto, não há dúvida de que eles praticavam o tráfico.

No ponto em questão, deve-se desde logo considerar que a apreensão recaiu sobre elevada quantidade, ou seja, nada menos do que 691,32 gramas de maconha (fls. 208).

Embora o acusado Júlio César tenha afirmado que trabalhava em serviço de pintura com seu pai, auferindo cem reais por dia, nada demonstrou a esse respeito, apesar de, insista-se, a prova do alegado pudesse ter sido facilmente produzida.

Por consequência, não se tem prova de que ele possuía numerário disponível para adquirir tamanha quantidade de entorpecente para mero deleite.

Continuando, a afirmação de Júlio César, no sentido de que comprava grande quantidade de droga para consumo para não ter que frequentar a boca de fumo, é incoerente.

Por mais que fosse trabalhoso dirigir-se por diversas ao ponto de tráfico, certamente assim proceder seria muito menos arriscado do que transitar com grande quantidade de droga e ser confundido com um traficante.

Para o senso comum, é preferível perder tempo para ir várias vezes ao ponto de tráfico do que se arriscar a ser preso como um traficante que transporta quase 700 gramas de maconha.

Destaque-se, ainda, causar espécie outra afirmação feita por Júlio César, agora a dar conta de que veio a Bauru a pedido de sua mãe, para dar um recado à irmã.

Como se sabe, atualmente se conta com dispositivos eletrônicos capazes de permitir comunicação rápida e instantânea, sendo o telefone celular o mais acessível e utilizado praticamente por toda a população.

Era, pois, muitíssimo mais fácil passar o recado por telefone, ainda que por chamada de vídeo via whastapp, do que dirigir-se de carro de Piratininga a Bauru para fazê-lo.

Reforça a conclusão em apreço a circunstância de o veículo dirigido por Júlio César estar, segundo o que ele próprio afirmou, com a documentação irregular.

A menos que o recado envolvesse teor ilícito ou criminoso, cuja transmissão por um meio ao alcance da justiça (interceptação telefônica) fosse arriscado.

Não vinga, igualmente, o argumento de que não seria possível realizar tráfico a bordo de um veículo, na posse de grande quantidade de maconha e sem instrumentos para fracionamento, pesagem e embalagem.

Ainda como se sabe, a efetiva venda de droga no varejo é somente o ponto culminante de toda uma cadeia criminosa que envolve diversas outras condutas, dentre as quais a de transportar entorpecente.

Não por outro motivo, diga-se, o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 menciona diversos verbos.

Na mesma ótica, cabe observar que referido dispositivo legal define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a transporte (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Portanto, se somente é possível concluir que os réus transportavam a droga com finalidade outra que não a de consumo próprio, não há como absolver e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao contrário, é de rigor a condenação na forma proposta na denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixam-se as penas base no mínimo legal para os dois réus, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, para ambos os réus.

O réu Júlio César não tem antecedentes criminais (fls. 65).

Em razão disso, mantêm-se as penas no mesmo patamar na segunda fase.

Já o réu Robson é reincidente (fls. 61/62 - art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Diante disso, elevam-se as penas na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na terceira fase, é incabível a aplicação do redutor ao réu Robson, na medida em que ele é reincidente.

Destarte, para Robson, são definitivas as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Já com relação ao réu Júlio, estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade e ausência de antecedentes, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

Acrescente-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida.

Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena.

Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado.

Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 - A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de

'atividade criminosa'. 2 - Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se

afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 - Recurso provido, para reduzir a pena

em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-

62.2013.8.26.0071).

Aliás, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reformou entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de restabelecer a causa de

diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim decidiu o eminente Ministro:

"Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito, essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Da leitura da decisão transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. O Tribunal de origem destacou que a paciente 'se dedicava à atividade ilícita de modo habitual e reiterado, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e que das circunstâncias em que foi surpreendida pelos policiais militares, isto é, por volta de 1h25 (...) tudo a indicar que não era principiante e fazia do comércio ilícito seu meio de vida, emergindo inegável, portanto, o seu envolvimento com atividades criminosas, notadamente com traficantes de maior porte, seus fornecedores ou patrões." Contudo, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a provar a afirmativa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, especialmente quando se observa que o Parquet somente arrolou como testemunhas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ora, a configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos e não de meras ilações, sem correspondência fática. O envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, como apontou a decisão atacada, pressupõe que o agente, no mínimo, pratica ou praticou diversos atos ou, ao menos, está inserido em grupo/organização direcionada ao crime. Entretanto, o ônus de provar tais elementos que afastam a redutora é da acusação, não cabendo ao magistrado colher elementos extraprocessuais para imputar uma reprimenda mais severa, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, o caso trata de condenação pelo tráfico de 7,67 (sete gramas e sessenta e sete decigramas) de maconha, mais 4,5 (quatro gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, ou seja, não se trata de quantia vultosa como afirmado no acórdão proferido pelo TJSP. Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de traficante primária e não há nenhuma indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas." (Habeas Corpus n. 137458/SP, j.

29/09/2016).

É certo que, no caso, a apreensão recaiu sobre 691,32 gramas, quantidade que não pode ser considerada pequena.

No entanto, segundo entendimento dos Tribunais Superiores (STJ e STF), a mera alusão à quantidade de entorpecente, dissociada de qualquer outra circunstância, não é hábil a caracterizar dedicação a atividade criminosa.

Cabível, pois, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Considerando, no entanto, que restou apreendida quantidade razoável de entorpecente, a redução da pena deve se dar no patamar de um terço, resultando em três anos e quatro meses de reclusão, mais trezentos e trinta e três dias-multa. Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para Júlio César. Ante o montante da pena aplicada e a primariedade, fixa-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena para o réu Júlio César.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas não serem das mais elevadas, entende-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, para o réu Júlio César.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a

redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Quanto ao réu Robson, ante o montante da pena aplicada e a reincidência específica, fixa-se o regime inicial fechado.

Pelos mesmos motivos, também lhe fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para: 1)- condenar o acusado Júlio César dos Santos como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar trezentos e trinta e três dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução e, 2)- condenar o acusado Robson Aparecido de Lima Francisco como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo.

Oportunamente, anatem-se as condenações no sistema informatizado.

O réu Robson foi preso em flagrante e permaneceu custodiado durante a instrução.

Agora, condenado a cumprir pena longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão há de permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a periculosidade evidenciada pela conduta de transportar drogas em situação de reincidência específica. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

O veículo apreendido estava sendo utilizado como instrumento para o transporte da droga e o proprietário sequer se dignou a pleitear sua restituição. Assim, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006, declaro o perdimento em favor da União. Oficie-se primeiramente à Senad, para os fins do § 4º do art. 62. Não vindo a Senad a manifestar interesse pelo bem, providencie-se o necessário para sua alienação por meio de leilão, na forma dos §§ 6º e seguintes do art. 62.

Em relação ao réu Júlio César, em razão da pena imposta, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

Bauru, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA